

1501145-43.2022.8.26.0617
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
1. Embora o recente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José dos Campos
Foro de São José dos Campos
2ª Vara Criminal
Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius
CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501145-43.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501145-43.2022.8.26.0617 2022/000776
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KAIQUE DE LIMA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

KAIQUE DE LIMA SANTOS e KENNEDY KAUAN DA SILVA, menores de 21 anos à época dos fatos, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 18.08.2022 (havendo erro material da denúncia quanto ao mês da ocorrência), por volta das 09h15min, na Avenida Airton Senna de Oliveira, altura do nº 270, Jardim São José II, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, transportavam, para fins de tráfico, 128 papérolas de cocaína, 52 porções de crack e 112 buchas de Cannabis sativa L, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Notificados os acusados para apresentação de defesa preliminar (fls. 161 e 163), veio aos autos à fls. 158/159 e 167.

Recebida a denúncia em 11.10.2022 (fls. 168/169), os acusados foram citados pessoalmente (fls. 223/226). Em audiência, foi colhida prova oral e os réus interrogados (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa dos acusados, a seu turno, buscou a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante relativa à idade de ambos os réus, afora confissão de KAIQUE; a aplicação da pena base no mínimo legal; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; a aplicação do art. 49, do Código Penal, no tocante à multa, por inconstitucional a previsão da lei de tóxicos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Os réus, interrogados em juízo, deram suas versões.

KAIQUE admitiu que na data transportava a droga até a "loja" a bordo de seu veículo e que ganharia para tanto R\$ 200,00. Já havia feito esta atividade por duas outras vezes. KENNEDY não tinha relação com os fatos. Apenas lhe deu uma carona até sua casa, encontrando-o quando saía do mercado após tentar comprar pão. Primeiramente deixaria o amigo em sua residência e depois partiria para o destino em que entregaria a droga (arquivo digital).

KENNEDY, por sua vez, alegou que na data saiu de casa para comprar pão. Chegando ao mercado, o pão ainda estava assando e desistiu da compra. Na saída do mercado, encontrou KAIQUE, que lhe ofereceu carona, sendo abordados pela polícia na sequência. O dinheiro que trazia consigo caiu no solo durante a ocorrência. Já respondeu a outros dois processos pela prática de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico, tendo cumprido as medidas socioeducativas que lhe foram cominadas (arquivo digital).

Os policiais civis ANDRÉ RICARDO VIERA, DANIEL MORAES SASAKI e WELLINGTON MACIEL TOMASSONI, asseveraram, em depoimentos seguros e harmônicos, que na data, tendo notícia do abastecimento de biqueiras do bairro, avistaram o veículo ventilado, que mudou de direção ao avistar a guarnição policial, ensejando a abordagem. Em busca veicular a droga foi apreendida em seu interior, assumindo um dos réus sua titularidade, afirmando o outro que iria comprar pão e estava de carona, mas nenhum dinheiro havia em sua posse (arquivo digital).

Os laudos periciais de fls. 21/30 e fls. 129/131 atestaram que as substâncias apreendidas cuidam-se de cocaína e tetrahydrocannabinol (THC), que, como se sabe, são drogas.

A confissão parcial de KAIQUE, afora palavra dos policiais, apreensão de droga no veículo por ele conduzido, bem como prova pericial, são elementos bastantes a demonstrar, no tocante a ele, a existência e autoria delitivas.

KENNEDY também deve ser condenado. Por primeiro, sua negativa, que o corréu

procurou secundar (conduta comum em tráfico em concurso de agentes), não convence.

De fato, inverossímil que o corréu, transportando droga, iria aumentar o risco de sua conduta parando o veículo para oferecer carona a pessoa alheia aos fatos, alongando e desviando seu trajeto original para deixá-lo em sua residência antes de chegar ao destino em que a droga seria entregue.

Não bastasse, a alegação de KENNEDY de que compraria pão não se compraz com a ausência de dinheiro em seu poder (mais uma vez não convencendo a escusa de que o dinheiro caiu de seu bolso durante a diligência).

A versão de KENNEDY, portanto, é inverossímil e rechaçada pelo conjunto probatório, estando comprovada a apreensão de significativa quantidade de droga, de natureza vária, no interior do veículo a bordo do qual estavam ambos os réus.

Sumulando, a palavra dos policiais, que, durante patrulhamento, apreenderam expressiva quantidade de drogas, de natureza vária (total de 204,54 g de "maconha" e 103,66 g de cocaína, fls. 21/30), na posse dos acusados, aliadas à prova pericial, comprovam, à saciedade, que os réus, agindo em concurso, transportaram a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação dos réus nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Deve ser decretada a perda do veículo apreendido em favor da União, porquanto instrumento do crime.

Saliente-se que a Constituição Federal determina a expropriação dos bens, em favor do Estado, que sejam instrumento, produto ou proveito do tráfico de drogas (art. 243, parágrafo único), devendo eventual direito de terceiro de boa-fé ser dirimido pela via própria.

Vejam-se as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários em que reconhecida a Repercussão Geral:

"TEMA 647. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento".

(RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

I – Réu KAIQUE

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, mormente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (total de 204,54 g de "maconha" e 103,66 g de cocaína), tudo a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes.

Sendo o réu menor de 21 anos à data dos fatos e confesso, reduzo suas penas ao piso, 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa, a despeito da primariedade do réu, ele admitiu que esta foi a terceira vez que transportava droga, a bordo de seu veículo, não sendo, portanto, traficante eventual ou de "primeira viagem", a despeito de não descoberto e coibidos os delitos anteriores pelo sistema de segurança pública. Não faz jus, portanto, ao redutor do § 4º do art. 33, da Lei de Tóxicos, ficando as reprimendas referidas definitivamente estabelecidas.

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A mera quantidade da reprimenda, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis, obstam a substituição ou concessão de sursis.

I - Réu KENNEDY KAUAN

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, mormente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (total de 204,54 g de "maconha" e 103,66 g de cocaína), tudo a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes.

Sendo o réu menor de 21 anos à data dos fatos, reduzo suas penas ao piso, 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Observo que o acusado admitiu haver respondido a feitos pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico quando adolescente, o que é corroborado pelos documentos de fls. 186/219 (processo nº 1500122-04.2018 – oportunidade em que foi cominada definitivamente a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade; processo nº 0015045-06.2016 – oportunidade em que foi cominada definitivamente a medida socioeducativa de liberdade assistida). Os atos infracionais foram perpetrados entre os anos de 2016 e 2018, sendo extinta a última execução de medida socioeducativa em julho de 2020 (fl. 198), havendo, portanto, contemporaneidade entre aqueles e a presente infração penal, perpetrada logo após o acusado atingir a maioridade. Outrossim, esta é a terceira vez que ele é flagrado traficando, não sendo traficante de "primeira viagem" ou eventual, não fazendo jus à causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33.

Nessa esteira a mais recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

1. Embora o recente entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, seja pela impossibilidade de utilização, por si só, da existência de ações penais em curso para o afastamento da causa de diminuição da pena do tráfico, é possível a utilização de atos infracionais como parâmetro para o seu afastamento a depender do caso concreto, notadamente quando o número de atos infracionais, a gravidade e o tempo decorrido desde o cometimento indiquem dedicação a atividades criminosas. Presentes tais requisitos, inviável a aplicação da minorante (...)."

(HC 674.746/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A mera quantidade da reprimenda, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis, obstam a substituição ou concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar KAIQUE DE LIMA SANTOS e KENNEDY KAUAN DA SILVA, menores de 21 anos à época dos fatos, qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 05 (cinco) anos de reclusão (regime inicial fechado), além de 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Decreto a perda, em favor da União, do veículo apreendido nestes autos.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deverão os acusados permanecer presos para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

Recomendem-se onde se encontram.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 30 de novembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA